

1500307-10.2021.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500307-10.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 19913441 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2661/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2234965 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Réu:

OSMAR FRANKLIN DOS SANTOS

Data da Audiência:

06/06/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 06 de junho de 2022, às 14 horas, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso das pessoas ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Alexandre Petry Helena - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, OSMAR FRANKLIN DOS SANTOS (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Amanda Palmieri Fração. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: José Roberto Carvalho Pinto e Marco Antônio Sodré.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, José Roberto Carvalho Pinto e Marco Antônio Sodré, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da

ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. OSMAR FRANKLIN DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, supostamente, no dia 28 de agosto de 2021, às 10:37 horas, na Travessa cinco, 85, Jardim Tarumã, Travessão, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, o acusado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico de drogas, 127 (cento e vinte e sete) porções de maconha, com peso de 159,78 gramas. A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2021 (fls. 77/78) O réu foi citado (fls. 90) e apresentou resposta à acusação (fls. 94/95). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, afasto a preliminar aduzida pela defesa de inobservância da inviolabilidade de domicílio dos acusados. Isto porque, a partir dos relatos dos policiais tanto em solo policial quanto em Juízo, infere-se que estes fizeram a abordagem policial na rua, sendo com o réu encontrado o entorpecente que estava em uma sacola. Somente após a localização das drogas, os policiais entraram na casa do réu com a sua autorização. De fato, adentraram à residência do acusado pautados por fundadas razões que levavam à presumir a configuração de flagrante delito de tráfico de entorpecentes. Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que

indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). V - Do contrário, devidamente analisado o pleito na origem, o eventual acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido". (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, o acusado estava em posse de grande quantidade de entorpecentes. No mérito, a ação é procedente. A materialidade está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls.12/13), auto de constatação preliminar (fl.14), laudos periciais (fls. 117/119 e 120/122) e demais provas produzidas nos autos. A autoria está comprovada. A testemunha e Policial Militar JOSÉ ROBERTO CARVALHO PINTO, disse, na delegacia, que na data dos fatos, durante patrulhamento pelo local dos fatos, região já conhecida como ponto de venda de drogas, um indivíduo posteriormente identificado como OSMAR FRANKLIN DOS SANTOS, estava saindo de dentro de uma residência, quando já estava do lado de fora, ao avistar a viatura se aproximando começou a correr desesperadamente em sentido contrário. Diante do ocorrido, os policiais foram atrás, logrando êxito em aborda-lo logo em seguida. Percebeu-se que este indivíduo estava com uma sacola em suas mãos, e que ao vistoriar nesta sacola, foram encontradas 127 porções de maconha já embaladas, semelhantes àquelas prontas para a venda, uma balança de precisão e um rolo de papel filme. Já em revista pessoal, foi encontrado em seu bolso a quantia de R\$4,00 (quatro reais). Ao ser indagado, este confessou que aquelas drogas eram para ele vender e que já tinha feito um "turno" durante a noite e, que já tinha entregue o dinheiro arrecadado para o "patrão" o qual disse ser um tal de "Luan", sendo que estava retornando para o ponto de venda novamente, para assim, continuar a vender aquelas porções que estavam em sua posse. Diante dos fatos os policiais lhe deram voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas por fundado receio de fuga, pois o mesmo já havia tentado fugir da equipe, sendo conduzido para esta delegacia, juntamente com o que foi apreendido. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e Policial Militar MARCO ANTONIO SODRE, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda, corroborando para sua versão. Em seu interrogatório, na fase policial, o réu OSMAR FRANKLIN DOS SANTOS, negou que estivesse vendendo drogas. Afirmou que

estava em sua moradia, sozinho e os policiais ali chegaram e perguntaram sobre entorpecentes, sendo que os entregou todo o material, pois realmente estava ocultando o entorpecente, e que estava na vida vendendo, pois teve alguns desacertos e se comprometeu em vender, para poder "pagar dívida". Alega que esta a cinco meses em liberdade devido a ter sido preso por tráfico de drogas e que já ficou preso por dez anos. Informa que estava apenas guardando: " guardei para um cara pela manha". Alega: "não adianta falar muito não, eu sei como é, já estava numa errada". Em Juízo, disse que estava na rua perto da casa de sua mãe. Quando viu a viatura fugiu para dentro de casa. Foi abordado dentro de casa. Tentou dispensar o entorpecente, mas não deu tempo. Estava com o entorpecente indicada na inicial. Não vendia drogas. Estava apenas guardando a droga em sua casa. Não estava com uma sacola na mão no momento

da abordagem policial. Nota-se que o réu confessou parcialmente a prática do crime. Disse que estava guardando o entorpecente, porém ressaltou que a abordagem policial foi dentro de sua residência. Esta alegação está isolada das demais provas constantes nos autos, por isso não merece credibilidade. De fato, o relato dos policiais foi uníssono e coeso no sentido que a abordagem foi na rua e só entraram na casa do réu para pegar a sua documentação e com a autorização dele. Assim, compreende-se que a declaração do réu é somente uma tentativa da defesa para anular as provas produzidas, mas que não pode ser acolhida conforme já fundamentado. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas. Isto porque, as declarações dos policiais, a confissão parcial e as demais provas produzidas nos autos demonstram a autoria delitiva. A dinâmica da abordagem, a forma de acondicionamento, a quantidade de entorpecentes denota que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilegal. Ademais, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347). Cediço, ainda, que não há impedimento de que o usuário seja também traficante. Ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08). Quanto à prova oral, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Vejamos: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles "podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Ainda, vale ressaltar que eventuais pequenas incongruências nas declarações são compreensíveis dado o decurso do tempo entre a abordagem policial e a realização desta audiência, contudo não são

capazes de retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares. Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosas, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Observando-se o acervo probatório produzido, nota-se que a prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, indicando que o acusado armazenava e praticava a mercancia dos entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. Por fim, ressalto que a versão do réu restou isolada dos demais elementos de prova produzidos nos autos. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, atendendo ao método trifásico da dosimetria. Fixo a pena para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, verifico que o réu possui maus antecedentes (fls. 114/116 - condenação por tráfico de drogas), além disso, considerando a significativa quantidade de drogas apreendidas, elevo a pena em 1/5 nesta etapa. Assim sendo, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Ressalto que a confissão parcial não se presta para reduzir a reprimenda. Presente a agravante da reincidência específica (fls. 114/116), razão pela qual elevo a pena em 1/6, resultando em 07 anos de reclusão além de 700 dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Tendo em vista que o acusado é reincidente específico e possui outras passagens policiais, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sendo assim, torno definitiva a pena de 07 anos de reclusão além de 700 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo regime FECHADO, tendo em vista a pena fixada, a gravidade em concreto do delito, bem como em virtude dos maus antecedentes e da reincidência específica. Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu OSMAR FRANKLIN DOS SANTOS, à pena de 07 anos de reclusão, em regime FECHADO, além de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Ressalte-se que a prisão cautelar do réu visa à manutenção da ordem pública, posto que evidenciada a prática reiterado do tráfico de drogas, além de outros delitos. Destarte, nego o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória. DECRETO O PERDIMENTO dos objetos e valores apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se

após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad; VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/E11eGRfiykt0mY2AdbJA6rYBDb8sZ4HWjG8S5rwh2oporg?e=tcGCUs